



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/22/2021
מס' בקשה: 5/564/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
דגנית קציר-ברין**

תובעים

1 **בן חיים שרה ואח'**

באמצעות ב"כ: עו"ד זיו גרומן
בר כוכבא 23, בני ברק

נגד

נתבעת

1 **לפידות טל ענת**

באמצעות ב"כ: עו"ד שרון סגל
בר כוכבא 23, בני ברק

**החלטה
(מתוקנת)**

1. התובעים הם בעלי 15 מתוך 16 דירות הבית המשותף שברח' בני דן 48 תל אביב-יפו, הידוע גם כגוש 6212 חלקה 149 (להלן: "**הבית המשותף**" או "**הבית**").

2. הנתבעת היא בעלת דירה הנותרת בבית משותף.

3. הרוב המכריע מקרב בעלי הדירות מעוניין לבצע פרויקט לחיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה באמצעות הריסת הבית הקיים והקמתו מחדש.

4. הנתבעת מתנגדת לביצוע הפרויקט מן הטעמים שהועלו בכתב הגנתה. וכפי שנכתב בפתח סיכומיה ביחס לשאלות המשפטיות:

בניגוד לרושם שבייכ התובעים מנסה להציג, הנתבעת אינה דיירת סרבנית, נהפוך הוא: למרות שהיא מבקשת להמשיך ולהתגורר בדירה הקיימת, שהיא דירת דופלקס בבניין אינטימי במיקום הטוב ביותר שיש לו חזית ירוקה הפונה לפארק הירקון – היא הודיעה מלכתחילה, כי היא לא תשים מכשול בדרכם של יתר התובעים המבקשים לשפר את דירותיהם, למגן אותן ולהתחדש עירונית, וכל מה שהיא מבקשת הוא דירת דופלקס דומת לדירה הקיימת ששטחה ושוויה יעלו בשיעור דומה לעלית שטח ושווי דירות התמורה של התובעים האחרים.

5. בדיון שהתקיים ביום 14.11.21, נתבקשו הצדדים לסכם טענותיהם ביחס לסוגיות המשפטיות שעלו, המהוות אבן נגף בניהול משא ומתן שבין הצדדים. ואלו הן:

א. **האם הנתבעת זכאית לפיצוי בגין 18 מ"ר שנבנו כתוספת שטח עיקרי לדירתה שלא עפ"י היתר בניה מספר ר' 95-1000 (מספר בקשה 94-1796) שצורף ע"י הנתבעת.**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/22/2021
מס' בקשה: 5/564/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ב. האם הפיצוי לבעלי הדירות צריך להינתן באופן שוויוני כמותי או עפ"י חלקם היחסי ברכוש המשותף, או עפ"י שווי דירותיהם.

6. לאחר שעיינתי בסיכומי הצדדים, אני סבורה כי הנתבעת אינה זכאית כי יובא בחשבון לצורך חישוב שטח דירתה העיקרי, שטח בהיקף של 18 מ"ר שנבנה בניגוד לדין שלא עפ"י היתר בניה.

בעמ"מ 8265/18 דגש לוג'יסטיק בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה - רמת השרון (נבו 13.01.2020) נקבעו דברים היפים לעניינינו :

"על פי סעיף 145(א)(2) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: החוק), המבקש להקים בניין חייב לקבל היתר לכך מאת רשויות התכנון. על כן, בניה בהעדר היתר כדיון, לא זו בלבד שאינה יכולה ליהנות מההטבות הניתנות על פי תכנית מאושרת, אלא דינה ללא ביצוע ההתאמות הנדרשות להיחרס. נקבע לא פעם ולא פעמיים כי על בית המשפט לתת את ידו למאבק בתופעת עבריינות הבניה, אשר הפכה זה מכבר למכת מדינה של ממש (ראו לדוגמה: רע"פ 4357/01 סבן נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה "אונו", פ"ד נו(3) 49 (2002); רע"פ 2041/11 קיבוץ יגור נ' הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז חיפה, [פורסם בנבו] פסקה י"ג (17.3.2011); עע"מ 6738/13 מדינת ישראל נ' ש.י. שפץ וקנין קבלני בניין בע"מ [פורסם בנבו] (2.12.2014); עע"מ 7344/16 הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים נ' ועדת הערר המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, [פורסם בנבו] פסקה 25 (28.8.2017)). אדרבה, באין הקלה או היתר לשימוש חורג, אם רשות התכנון תעניק היתר בניה שאינו תואם את התוכנית הרלוונטית, היא נתפשת כמי שפעלה שלא כדין (עע"מ 2015/08 בר-און נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה - מטה יהודה, [פורסם בנבו] פסקה 8 (31.12.2012))."

האמור לעיל נקבע אמנם ביחס לבניה ללא היתר, אך, לדעתי, הדברים נכונים ויפים גם למקום בו קיימת חריגה מהיקף הבניה שהותר במסגרת היתר הבניה.

7. הנתבעת הודתה בהגינותה כי שטח החריגה אינו כלול בשטחים המקנים תמריצי תמ"א ראו פסק הדין לעיל, ברם, היא סבורה כי הגם שכך, לשטח הרלבנטי קיים ערך כלכלי בגינו מגיע לה פיצוי.

8. לדידי, אין לאפשר לחוטא לצאת נשכר כתוצאה מעבירת בניה בין שהוא ביצע אותה בעצמו ובין שרכש את הנכס כמות שהוא. דהיינו: הדברים אמורים הן ביחס לבעל הדירה שביצע את עבירת הבניה בעצמו, שאז בוודאי אין הוא זכאי לדרוש בגינה פיצויים, אך הם נכונים, לדעתי, גם ביחס למי שרכש את הדירה מאותו עבריין בניה. חזקה על הנתבעת כי בעת רכישת הדירה, בחנה את מצבה המשפטי, ובחרה לרכוש אותה במצבה זה על כל המשתמע ממנו.

9. אציין כי, בתיקון מס' 7 לחוק פינוי בינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי) התשפ"א, 2021, נקבע כי ביהמ"ש רשאי לקבוע כי לא יובאו בחשבון זכויותיו או חלק מזכויותיו של בעל דירה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/22/2021
מס' בקשה: 5/564/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שלא הסכים לכריתת עסקה לפינוי ובינוי אם מצא שהתנגדותו נובעת מבניה או משימוש שלא כדין. ההסדר שנקבע בחוק דן, קובע כי בעל דירה שביצע עבירת בניה לא יבוא בחשבון במניין בעלי הדירות בבית המשותף לצורך קביעת הרוב המיוחס. האמור לעיל, מלמד כי המחוקק ער לאפשרות שבעל דירה ביצע עבירות בניה ומבקש פיצוי בגינה **ועל מנת למנוע פעולה שכזו**, מצא לשלול את זכותו של בעל דירה שכזה. בעניינינו, לא חלה אמנם הוראת החוק הנ"ל, בהיות הפרויקט בפני פרויקט חיזוק, עם זאת, יש בהסדר דלעיל כדי ללמד על הלך הרוח של המחוקק ועל היחס שיש, לכאורה, ליתן לבעל דירה המבצע עבירות בניה כאמור (או רוכש דירה הכוללת עבירת בניה).

10. יודגש כי אפילו ניתן היה לקבל היתר בניה, בגין הבניה הרלבנטית ולהכשירה (מבחינה תכנונית) אין בכך די. שכן, מבחינה קניינית, לא די בקיומו של היתר בניה, זכויות הבניה שייכים לכלל בעלי הדירות.

אמנם, התקנון המוסכם של הבית המשותף הצמיד לדירה מס' 16 שטח גג של 91 מ"ר, אולם, משלא הוצמדו זכויות הבניה לגג דן, אזי מדובר בנכס משותף לכלל בעלי הדירות ומשכך מימוש זכויות הבניה ובניה על גבי ההצמדה, מחייבת הסכמת בעלי הדירות ברוב הקבוע בחוק המקרקעין קרי 75% מבין בעלי הדירות אשר שני שליש מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם.

בנסיבות דהיום מקום שבעלי הדירות, ברוב מכריע (15 מתוך 16 דירות הבית) מעוניינים בביצוע הפרויקט הרלבנטי, אזי לא מוקנית לנתבעת הסכמתם למימוש זכויות אלו. יודגש כי עצם האפשרות לקבל היתר לפי תכנית, עוסק בפן התכנוני בלבד ואולם בפן הקנייני הזכויות הרלבנטיות, בהעדר וויתור מפורש מצד בעלי הדירות, אינן מוקנות לנתבעת.

11. המושג 'זכויות בניה' מתייחס **"לפוטנציאל הבניה הקיים והעתידי שמותר לבנות על חלקה מסוימת בהתאם לתוכנית מתאר ע"פ חוק התכנון והבניה. אחוזי בניה שלא נוצלו מעניקים לבעלי החלקה 'זכויות בניה'. והם רשאים לממש את הזכות לבנות לאחר שקבלו היתר בניה ע"י וועדה לתכנון ובניה"** (ראו: א' איזנשטיין, **יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי- בתים משותפים (התשס"א- 2001)** בעמודים 147-148).

12. זכויות בניה בבית משותף אינן בגדר "רכוש משותף" כהגדרתו בחוק המקרקעין. המדובר בנכס בעל ערך כלכלי, הנמצא בבעלות משותפת של בעלי הדירות (ראו ע"א 136/63 יוסף נ' **שוורצמן**, פ"ד יז 1722, 1726; ראו גם רע"א 7112/93 **צודלר נ' יוסף** פ"ד מח(5) 550, 571).

13. בע"א 7156/96 **שואעי נ' בכרך**, נג (1) 469 (1999) נקבע כי: **"זכויות הבניה בבית משותף שייכות (מכוח בעלותם המשותפת בקרקע) לבעלי כל הדירות בבית, וניצולן על-ידי בעל דירה מותנה בהסכמת יתר בעלי הדירות."**

14. לא מצאתי בתקנון המוסכם של הבית התייחסות לזכויות בניה או להצמדתן לדירה מסוימת או לויתור עליהן.

15. בהעדר ויתור מפורש על זכויות הבניה מצד יתר בעלי הדירות לא זכאית הנתבעת לעשות שימוש בזכויות אלה ללא הסכמתם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/22/2021
מס' בקשה: 5/564/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

16. באשר לשאלה השנייה שנתבקשתי להכריע בה, קרי האם התמורות לבעלי הדירות במסגרת פרויקט תמ"א 38 הריסה ובניה מחדש, אמורות להינתן באופן שוויוני מהותי כמותי או בהתאם לחלקם היחסי של הדירות ברכוש המשותף או עפ"י שווי דירותיהם, הרי שאך לאחרונה ניתן פסק דין ע"י כב' ביהמ"ש המחוזי בעניין עשא (ת"א) 14413-02-22 שלמה שוחט נ' יוכבד פרץ (נבו, 26.4.22) (להלן: "עניין שוחט") שם נקבע בסעיף 33 לפסק הדין:

"השאלה השנייה לה נדרשתי בעניין ניסני, נסבה על מהות השוויון בין בעלי הדירות. אשר לכך, קבעתי כי לעמדת השוויון הרלוונטי לענייננו הוא השוויון המהותי ולא דווקא השוויון הכלכלי. תימוכין מרכזי לקביעתי זו מצאתי בהוראות תמ"א 38 ובתמריצים אשר היא מקנה. תמריצים אלו – בכל הנוגע לבעלי הדירות הקיימות – כוללים תוספת שטח והטבות זהות לכל אחת מהדירות וזאת בין אם מדובר בדירה גדולה ובין אם מדובר בדירה קטנה, בין אם מדובר בדירה אשר שוויה ההתחלתי גבוה יותר ובין אם נמוך ובין אם מדובר בדירה בקומה גבוהה יותר ובין אם בקומה נמוכה. כך, בהתאם לתמ"א 38, התמריצים הם אחידים – תוספת שטח מקסימאלי של 25 מ"ר – באופן קטגורי לכל דירה – קטנה או גדולה. זאת, הגם שלדירה קטנה מוקנה שיעור קטן יותר של הרכוש המשותף מזו של דירה גדולה וכפועל יוצא מכך על פניו גם תרומתה לפרויקט – קטנה יותר מזו של דירה גדולה. לכך יש להוסיף ולציין כי בפרויקטים של חיזוק מתווספת ככלל מעלית לבניין אשר ברי כי ערכה הכלכלי לדירות הגבוהות גבוה מזה שיתווסף לדירות הנמוכות יותר. מכל האמור נובע כי הדגש בתמריצים הניתנים במסגרת התמ"א אינו על תמריצים זהים כלכלית אלא על תמריצים זהים מהותית-כמותית.

יתרה מכך, בפרויקט מסוג תמ"א 38/2 - קרי בפרויקט בו נהרס הבניין ונבנה על ידי היזם מחדש, מתחדד עוד יותר – מבחינת נקודת הראות של היזם - העדר הרלוונטיות לשוויון הכלכלי ההתחלתי של הדירות. זאת הואיל ובפרויקט כאמור, נהרס הבניין ונבנה מחדש ומשכך מנקודת ראותו של היזם – תרומתה של דירה מטופחת, השווה במצבה ההתחלתי יותר, זהה לתרומת דירה שאינה מטופחת בשווי התחלתי נמוך יותר – באשר תרומתה של זו גם זו מתמצית בחלקה במקרקעין עליהם בנוי הבניין, הא ותו לא. בהתאמה לכך, אקדים ואציין כי לעמדתי, קביעה שדירה השווה יותר במצבה ההתחלתי תהיה זכאית לקבל תוספת תשלום או פיצוי כספי לאור זאת, משמעה הכנסת אלמנטים אשר אינם רלוונטיים ליזם, למערכת היחסים בין בעלי הדירות לבין היזם. שכן, כאמור מנקודת המבט של היזם, אין כל רלוונטיות לשווייה ההתחלתי של הדירה.

אציין כי תימוכין נוסף לקביעתי ולפיה השוויון הרלוונטי לענייננו הוא הכמותי ולא הכלכלי, ניתן למצוא בדברי בית המשפט העליון בעניין דורפברג, אשר הובאו לעיל ובהתאם להן האינטרס המוגן על ידי תמ"א 38 אינו האינטרס הפרטי של בעלי הדירות להשיא רווחיהם ולשפר מצב דירותיהם, אלא, האינטרס הציבורי בחיזוק המבנים.

ריכוז האמור מלמד ראשית שבחינת השוויון בין התוספות לכל אחת מהדירות יבחן קטגורית, כאשר "כלל האצבע" יהיה האם כל אחת מהדירות זוכה לתוספות שטחים דומות במהותן, בהבדל מדומות בשוויון או בתוספת הערך שהן מוסיפות לכל אחת מהדירות. שנית – שעל מנת שהתנגדותו של המיעוט תשמע, הרי שעליו להראות כי הפגיעה בזכויותיו היא מהותית שאם לא כן, המזור לדייר כאמור יהיה, לכל היותר, בתשלומי פיצוי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/22/2021
מס' בקשה: 5/564/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. לפיכך אני דוחה את טענת הנתבעת לפיה השוויון בתמורות אמור להביא בחשבון את שיעור החלקים ברכוש המשותף או לעמוד ביחס מתאים לשווי הדירות הנוכחי.

18. לא מצאתי בפסק הדין בעניין עש"א (מחוזי ת"א) 50506-09-19 **סיגל יעל נ' עמנואל באומלשפינר** (נבו 15.01.2020) תימוכין לטענות הנתבעת. איני סבורה כי קיימת סתירה בין פסק הדין בעניין באומלשפינר לבין פס"ד בעניין ניסני. מכל מקום, אפילו הייתה קיימת סתירה ביניהם, אזי פס"ד בעניין שוחט מבהיר בצורה בלתי משתמעת לשתי פנים מהי עמדת ערכאת הערעור באופן שאינו מתיישב עם עמדת הנתבעת בתיק זה.

19. לאור האמור לעיל, אני מורה על קיום דיון ההוכחות שנקבע במועדו בגדרו ידונו יתר טענות הצדדים.

ניתנה היום י"ד אייר, תשפ"ב (15 מאי, 2022) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.

דגנית קציר- ברין
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו